



从国家构建到共建共享的法治转向

——基于社会组织与法治建设之间关系的考察

马长山^{*}

内容提要：近四十年来，社会组织与法治建设之间的关系，在整体上呈现出一条以国家构建为主导的路线图。其间，政府监管部门在徘徊变革中力图打造“以社会管社会”的新格局，但功效欠佳；社会组织则在曲折成长中践行着民间构建行动，但作用乏力。这就导致法治进程中社会组织的功能性“不在场”，并促发了“两极结构”怪圈、汲取性机制风险、自律秩序不足、国家构建与民间构建错位等问题，严重制约了治理法治化秩序的生成。在“四个全面”战略布局下，从国家构建到共建共享的转型已成大势所趋，目前亟需重塑社会组织在法治建设中的使命和功能，进而迈向共建共享型的“法治中国”之路。

关键词：社会组织 国家构建 共建共享 法治秩序

中国已进入改革深水区和转型关键期，法治建设也开启了“全面推进”的新阶段。归整改革开放近四十年的法治建设经验与教训，揭示法治建设的现实进路并提炼其中的问题，对推进法治中国战略的深入实施具有重要意义。本文拟以近四十年社会组织（民间组织、NGO）发展与法治建设之间的关系为出发点，力图审视、分析和展望其中所蕴含的从国家构建到共建共享的重要法治转向，为当下法治中国建设提供反思研判和理论支持。

一、国家对社会组织的构建策略

从理论上讲，国家构建就是“在强化现有的国家制度的同时新建一批国家政府制度”，^{〔1〕}它是近代以来国家的一个经常性制度化规制活动，是国家以公益为由，进入社会并力图影

^{*} 华东政法大学教授。

本文为国家社科基金重点项目“‘法治中国’建设中的基层治理法治化路径与策略研究”（15AFX002）的阶段性成果之一。

〔1〕〔美〕弗朗西斯·福山：《国家构建——21世纪的国家治理与世界秩序》，黄胜强等译，中国社会科学出版社2007年版，序言，第1页。





响和塑造社会的重要方式。然而,国家构建必须以国家与社会之间的良性互动为前提和基础,必须反映社会发展的现实需要和公众诉求,构建过程也必然趋向于“在特定地理区域内,基于共同语言和文化基础上的,共有的国家认同的形成”。^{〔2〕}这就是说,尽管国家构建展现着国家的自主性和对社会的规制取向,却离不开民间力量相应的互动回应、反思修正和构建参与,也不能忽视它与社会自我构建过程的互动平衡。

就中国而言,无论是出于历史惯性还是基于现实考量,国家构建都具有举足轻重的地位和影响;但同时,改革开放后社会组织开始大量兴起,并成为民间参与的新生力量和社会建设的主力军。这就造成了国家构建与民间参与之间的复杂整合和特殊张力,特别是在社会组织监管体制和制度建设上尤为明显。

(一) 徘徊变革中的国家构建努力

也许是基于对转型期稳定的考量以及对改革发展整体性研判的不同视角,在政府对社会组织的“放”与“管”上,很多时候表现出一种纠结与徘徊。

一是社会组织立法方面的徘徊。任何一个国家的社会组织发展,首先都要依托于国家立法的方向指引和规范框架,中国也不例外。1950年9月政务院颁布《社会团体登记暂行办法》,确定了新中国的社会组织立法基调,但在此后较长时段内,相关立法几乎没有任何进展,直到1989年10月国务院颁布《社会团体登记管理条例》,方开始新的立法进程。此后,民政部力图在单行性、程序性办法或条例的基础上,尝试推动制定统一的结社法。1990—1992年间,民政部社团司基于“清理整顿”和加强社团管理的需要,起草了结社法草案,但该法最终并未出台。1998年,国务院修订了《社会团体登记管理条例》,着眼于“管”的“双重管理体制”仍得以保留,其主导取向依然是以控制为主导的“预防制”。

由于社会组织以稳健上升的态势快速壮大,这些程序性的“条例”远远不能满足现实的需要。当时,民政部逐渐搁置了统一的实体立法的思路,转而寄希望于通过对社会组织“三大条例”(社会团体、民办非企业单位和基金会条例,下同)的修改,进行重要的制度变革和创新,并鼓励广东、北京、上海等地“先行先试”来做一些制度探索。然而,“三大条例”却迟迟未能顺利修改,相关配套措施也未能发布。直到2016年8月1日,民政部才发布了《社会团体登记管理条例》修订草案征求意见稿。“征求意见稿”反映了一些重要的改革举措和探索创新成果,但从登记与管理制度的内容来看,依然带有某种“妥协”迹象和管制主义倾向。

从近四十年社会组织立法的整体走向来看,登记管理机关在统一立法还是分散立法上,在“双重管理体制”的废立上,在采取“预防制”还是“追惩制”上,既有倾向前者的动力和压力,又有选择后者的无奈和徘徊。这就形成了立法中的控制主义和管理中一定程度的放任主义相并行的特征。^{〔3〕}

二是管理体制改革的纠结。中国加入WTO后,成立社会组织的民间需求也迅速增长。广东、北京、上海、浙江等地社团管理的创新探索表明,社会组织的繁荣发展可以为政府减轻很多负担。然而,在“双重管理体制”之下,找不到业务主管单位的社会组织便

〔2〕〔美〕德里克·W.布林克霍夫:《冲突后社会的治理:重建脆弱国家》,赵俊等译,民主与建设出版社2015年版,第41页。

〔3〕参见刘培峰:《社团管理的许可与放任》,《法学研究》2004年第4期,第149页以下。



采取了“私下”活动,游离在监管之外,这导致有数百万之众的社会组织处于“监管真空状态”;^[4]而一些官办组织行政化倾向较为严重,“这些社团组织滥用权力、到处敛钱、缺乏活力”。^[5]为此,国家监管部门开始启动社团管理体制改革,试图改变过去备受诟病的“双重管理体制”,确立以保障自由和权利为导向的“直接登记”制度。2011年,国家“十二五”规划纲要首次设专章阐述“加强社会组织建设”的改革思路,明确了“20字方针”。^[6]2012年3月第十三次全国民政工作会议提出了“公共服务可适当交给社会组织承担”,对一些社会组织采取直接登记的改革举措。然而,这些改革举措并没能及时落地。

(二) 国家构建努力上的难题

基于加强社会组织管理和党建的需要,国家监管部门不断鼓励各地根据本地实际进行实践创新,并把社会组织孵化器和“枢纽型”社会组织作为各地探索的典型成果来推广。这明显体现了国家构建的重要努力,并对社会组织监管体制改革和制度发展产生了至关重要的作用和影响。

社会组织孵化器(又称“孵化园”、“孵化基地”、“培育中心”、“培育基地”等),是在借鉴企业孵化器理念与实践经验的基础上,从2006年起先后在上海、深圳、北京、广州、宁波、太原等地发展起来的。其背景在于:在公共服务社会化的进程中,社会组织必将成为承接政府资源、吸纳社会资源,组织群众互助互帮、共建共享,践行创新公共服务的重要社会主体;而目前我国社会组织建设明显滞后、整体上也很弱小,迫切需要建立一种政府和社会组织都能够充分信赖的机构,为初创期或实力弱小的社会组织提供专业指导、资金项目等全方位支持,增强其独立运作的能力。^[7]社会组织孵化器旨在为社会组织创造和提供支持性环境,不仅包括物理性支持、资金支持、行政办公辅助等一般意义上的基本服务,它还提供增值服务,如能力提升、协调推广、财务托管、法律咨询等,并形成了政府主办、政府运营民间主办、民间运营政府主办等不同模式。在一些实务研究者眼中,这些探索能够准确地把握和反映社会组织的困难与需求,降低社会组织的创业成本和运作成本,提高社会组织的成活率,也为政府管理社会组织提供了一种卓有成效、安全可控的创新模式,搭建了多方共赢平台,加强了各方相互认知。^[8]

枢纽型社会组织是2008年9月在北京市社会建设大会上出现的一个新概念。2009年3月北京市发布的《关于构建市级“枢纽型”社会组织工作体系的暂行办法》第2条,将其界定为:“由市社会建设工作领导小组认定,在对同类别、同性质、同领域社会组织的发展、服务、管理工作中,在政治上发挥桥梁纽带作用、在业务上处于龙头地位、在管理上经市政府授权承担业务主管职能的市级联合性社会组织”。在随后的发展中,无论实务界还是理论界,都对枢纽型社会组织的定位与功能产生了不同看法:一是立足国家管理维度,认为枢纽式管理是“用党和政府控制下的社会公共服务组织去管理同一门类的民间组织”

[4] 参见申欣旺、陶旺波:《双重管理的优势已用尽》,《中国新闻周刊》2012年第17期,第66页以下。

[5] 孙伟林:《社会组织管理体制改单势在必行》,《中国非营利评论》2013年第2期,第96页。

[6] 即“统一登记、各司其职、协调配合、分级负责、依法监管”。

[7] 参见孙燕:《社会组织孵化器——实现公益事业可持续发展的助推器》,《社团管理研究》2011年第6期,第48页。

[8] 参见王世强:《非营利组织孵化器:一种重要的支持型组织》,《成都行政学院学报》2012年第5期,第83页以下;郑碧强:《实现公益组织孵化器可持续发展》,《中国社会科学报》2015年5月8日B02版。



的管理方式；^{〔9〕}或者是“由政府权威部门认定的，在现有的社会组织体系获得中枢与超然地位，从而代替政府对其他社会组织进行管理与指导、服务的社会组织”，具有合法性、排他性、资源整合性和代表性四大特征。^{〔10〕}二是立足联合的中介维度，认为枢纽型社会组织是经授权承担国家规定的业务主管单位职能的联合性组织，其实质是促使相同类别、性质、领域的社会组织共同进步、共同发展的一个组织者，是处在政府管理部门和社会组织之间的社会组织联合体，它服务和管理一个地域、系统或领域的社会组织，实现工作方法由管理型向服务型的转变。^{〔11〕}三是立足整合的共治维度，认为枢纽型社会组织是新时期的一种“整合、代表、合作”组织。它作为在政府管理部门和社会组织之间的一个重要载体，发挥着服务和管理一个系统、领域的社会组织的功能，也行使一部分党和政府授权或委托的职能，并把社会组织的需求、意见和建议向政府管理部门反馈，使其成为“加强党建工作的支撑、完善双重管理的依托、凝聚团体会员的载体和实现合作共治的平台”。^{〔12〕}其最关键的角色并不是政府管理的代表者，而是“能发挥枢纽作用，能得到多数社会组织和公众的认可”，从而摒弃了自封的或政府单方认定的枢纽型组织角色。^{〔13〕}

不论社会组织孵化器还是枢纽型社会组织，它们的出现都是国家加强行政培育、强化管理、着意国家构建的重要努力。^{〔14〕}这些努力有利于应对社会组织迅速发展的态势，但也存在不少问题。

其一，发展社会组织孵化器和枢纽型社会组织，仍是一种国家导入社会的构建活动。社会组织孵化器和枢纽型社会组织固然会有其积极促进、提升效率与维护秩序的一面，但它们毕竟是官方或半官方的人为设计平台，其实质乃是行政给定的一种领域性统驭组织，而非自愿形成的联合体。这种管理体制呈现的是一种纵向隶属关系，而非横向平等关系。社会组织孵化器和枢纽型社会组织的职责主要是领导和控制，而后才是指导和帮助。“由于枢纽组织的官办性质、官僚身份和行政化运作，使‘枢纽型社会组织’这一社会组织管理体制创新，不仅面临‘换汤不换药、新瓶装旧酒’的尴尬，而且还有明显的政社混淆、资源垄断、危及公平等不良现象。”^{〔15〕}这样，也就“容易出现管理层级增加、组织利益分割、组织间关系难以协调、业务指导有偏差等消极后果”，因而需要“考虑综合运用多样化的管理体制，以达到全面覆盖、协调运作、有效管理的目的”。^{〔16〕}这种表面上的“以民管民”、“以社会管社会”方式，实际上造成了管理上更多的问题与困境，也与“负面清单”模式下充分发挥社会组织作用的监管体制改革要求和趋向明显不符。

〔9〕 方士雄：《顺应改革需要进行枢纽式管理》，《中国社会报》2006年11月6日005版。

〔10〕 参见崔玉开：《“枢纽型”社会组织：背景、概念与意义》，《甘肃理论学刊》2010年第5期，第77页。

〔11〕 参见冯志明：《共青团“枢纽型”社会组织建设浅探》，《思想教育研究》2011年第10期，第85页；张大明：《静安区“枢纽型”社会组织管理模式的运作及思考》，《社团管理研究》2012年第2期，第54页。

〔12〕 曾永和：《培育综合性社会组织 促进社会组织管理创新——上海市推进社会组织枢纽式管理的调查与思考》，《社团管理研究》2011年第8期，第52页。

〔13〕 尹志刚、李泓：《关于构建“枢纽型”社会组织工作体系的调查与思考》，《北京行政学院学报》2009年第6期，第80页。

〔14〕 有些地方还提出以党建引导社建的创新管理模式，以期形成政府主导的“以民管民”、“以社会管社会”的管理机制，参见卢建等：《北京市构建社会组织“枢纽型”工作体系的实践与策略》，《社团管理研究》2011年第9期，第28页。

〔15〕 马庆钰：《纠正枢纽型社会组织的发展偏向》，《行政管理改革》2015年第10期，第47页。

〔16〕 李璐：《分类负责模式：社会组织管理体制的创新探索》，《北京社会科学》2012年第3期，第51页。



其二, 枢纽型社会组织若发挥其法治功能, 则需具备相应的规则与前提。西方并没有与“枢纽组织”相类似的概念, 但并不缺乏相似的组织,^[17]只不过他们往往采取“议题联盟”(以表达共同议题为纽带)、“网络结构”(基于共同议题的长期互动交流机制)和“伞状结构”(自治条件下的制度化联合管理机制)等不同的联合组织形式。就中国而言, 对发展具有一定影响的枢纽型组织也可以持开放态度, 但前提是它必须合乎联盟型组织的治理规则, 符合政社分开、依法自主、平等发展的基本要求, 这“才能有利于所属领域社会组织的发展, 也才使中国现有枢纽型社会组织找到存在的价值和理由”。^[18]如果枢纽型组织建设缺少这些规则和前提, 就会失去其应有的作用和功能, 很容易堕入单纯的国家构建和行政控制的机制状态之中。

其三, 国家构建方式虽然保证了秩序, 但社会组织却付出了被“收编”的代价。国家对社会组织的监管, 无疑都要有规范和秩序上的考虑, 然而, 这些规范和秩序上的目标, 却未必一定要通过国家构建的方式来实现。过度的国家构建会产生政府普遍“收编”和过度控制社会组织的状态, “它通常产生于 NGO 对更多资源的需求与政府想控制 NGO 而发生的冲突中”。^[19]这不仅造成了社会组织的行政依附性, 也难以建立有活力的、可持续的秩序。当前, 社会组织孵化器和枢纽型社会组织体现着更强的国家构建性和官方意志性, 力图实现社会组织的“再体制化”或“体制化”的延伸, 这就使得社会组织在合法性、制度环境、治理角色和法治功能等方面, 处于较为尴尬的境地。为此, 社会组织更多地采取基于共同规划和实施项目的“田野合作”方式, 而不是基于独立运营、相互支持的“平行合作”方式, 来建立与政府的互动关系, 它们并未展示出多少革新示范作用, 而“只是做了公益事业”。^[20]这样, 社会组织在法治进程中的功能与作用就必然受到严重制约和影响。

二、社会组织发展的中国境遇

随着我国的经济发展和社会分化, 人们结社的愿望和需求也越来越高。然而, 面对迅速崛起的社会组织, 国家构建的策略一直在不断推进, 但其制度供给却明显不足。这不仅使国家难以有效发挥其应有的引导和规制作用, 而且导致社会组织成长与发展面临一定的尴尬问题, 特别是民间力量在国家构建过程中的回应反思、互动参与遇到了明显障碍, 社会自我构建能力出现了严重不足。

(一) 空间环境与民间构建行动

这里所说的“空间环境”, 主要是指社会组织所处的包括制度、政策、机制、文化、社会环境等在内的整体生存空间, 它决定着社会组织的成长方式和发展道路。中国的社会组织发展, 是一种典型的“政府主导”模式, 具有明显的官民双重性, 存在包括宏观鼓励与微观约束、分级登记与特权豁免、双重管理与多头管理、政府法规与党的政策、制度剩余

[17] 参见刘忠祥等:《美国非营利组织运作和管理的启示与思考——民政部赴美国代表团学习考察报告》,《社团管理研究》2011年第3期,第19页以下;王劲颖:《美国基金会发展现状及管理制度的考察与借鉴》,《中国行政管理》2011年第3期,第58页以下。

[18] 前引[15],马庆钰文,第49页。

[19] [美]朱莉·费希尔:《NGO与第三世界的政治发展》,邓国胜等译,社会科学文献出版社2002年版,第37页。

[20] 同上书,第122页以下。

与制度匮乏等方面的困难与问题,这就导致社会组织不成熟,在制度资源、文化基础、经济实力、领导威望等方面出现不规范、不平衡等问题。基于这种特殊的空间环境,社会组织在顺应国家构建策略、调整自身发展方式的同时,又试图通过积极投身国家和社会生活,努力参与国家构建的过程,并积极开展可能的社会自我构建行动,包括对国家制度变革的反思诉求、社会行动中的自我赋权和自律秩序的塑造等。社会组织的民间构建行动呈现以下几个特征:

一是在合法性困境中谋求发展空间。据民政部《社会服务统计季报》(2016年4季度)显示,截至2016年底,全国民间组织有74.9万个,其中,社会团体33.5万个,民办非企业单位35.9万个,基金会5523个。然而,大量的、活跃在基层社会的各类草根组织并不在此统计数字之内。这样,虽然一个以人民团体、准政府社团、登记注册的社团、草根社团为主体的“多元化的版图”得以形成,^[21]但占总数80%以上的社会组织,却因无法取得合法登记身份而存在着明显的合法性困境。^[22]

在一些西方发达国家,社会组织也未必都要取得“合法”身份(法不禁止即合法),其相应的正常业务活动并不受太多影响。但中国的关键问题是,在面对以控制和管理为取向的监管体制,而民众又习惯于依赖政府规划而非民间自主的社会环境时,合法身份就显得十分重要了。没有合法身份,就意味着在政府认可和社会认同上“名不正言不顺”,因而,这些社会组织始终有一种“朝夕不保”的忧患意识,也难以获得制度上的同等待遇和政策惠顾,社会动员能力也必然受到局限。为此,它们就会有意无意地去谋求社会合法性、行政合法性或政治合法性,以保证其能在与法律不一致的情况下正常地开展活动。^[23]它们在“合法”与“非法”的制度夹缝中,努力凭借社会需求和公益增量的“无害”活动,来进行自我赋权、获取政府默认和展现公信力,进而积极拓展自身的发展空间,特别是在为民服务、公益慈善、纠纷解决、文体娱乐、帮扶矫正、维护治安等方面,参与社会治理和开展民间构建行动,成为和谐秩序的重要建设者。基于此,有学者呼吁,要平衡“管理”和“确权”两种立法取向,实现从控制型管理转向培育服务型管理。^[24]而这就要“改变目前这种把民间组织当做政府管理对象、生怕它出乱子、给政府找麻烦的思维定势,而应转变观念,引导民间各种潜力成为一种和政府合作、促进社会事业发展的力量,共同为中国的经济腾飞和社会发展出力”。^[25]最近出台的《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》(以下简称“社会组织促进意见”)提出,要鼓励社区社会组织综合服务平台和社会力量,支持社区社会组织发展。这无疑是向好的方向,只是它仍在“社会组织孵化机制”的框架中进行,国家构建色彩依然明显。

二是“生存资金来源于谁,也就为谁服务”。基于在动员能力和资源获取上的艰难,社会组织难免会有一些很务实的考虑。其中,依靠政府拨款的,就对政府依赖性强,扮演着政府职能的延伸角色,而对会员、对社会的服务性不够,会员参与性也不高。相反,那些

[21] 参见何建宇、王绍光:《中国式的社团革命——对社团全景图的定量描述》,载高丙中、袁瑞军主编:《中国公民社会发展蓝皮书》,北京大学出版社2008年版,第163页。

[22] 参见谢海定:《中国民间组织的合法性困境》,《法学研究》2004年第2期,第17页以下。

[23] 参见高丙中:《社会团体的合法性问题》,《中国社会科学》2000年第2期,第100页以下。

[24] 参见前引[22],谢海定文,第32页。

[25] 苏力等:《规制与发展——第三部门的法律环境》,浙江人民出版社1999年版,第201页。



没有政府拨款、依靠会员来筹集资金和整合资源的“自下而上型”社会组织，其会员参加活动、参与决策的积极性则普遍较高，为会员的服务能力也更强。^[26]

三是参与的领域开始从边缘迈向中心。过去，除了一些有官方背景的外，大多数社会组织参与社会事务的范围狭窄，参与的程序和渠道并不规范，也不顺畅。它们基本上活动在政治敏感度低、权力和利益含量少的边缘领域，如环保、教育、扶贫开发等，参与质量也不高。然而，近年来这一情况部分地发生了改变，有些社会组织的参与活动从社会的边缘逐渐推进到公共政策的中心地带，由回避敏感问题到开始关注、参与敏感问题的讨论。同时，部分社会组织已从单打独斗到合作交流，从默默无闻到积极谏言，在影响公共政策方面做出了重要努力。如保护藏羚羊、叫停“杨柳湖”水电工程、组织“北京动物园搬迁事件”大讨论、阻止怒江水电开发计划、召开“圆明园铺设防渗膜事件”听证会等等，都引起了各界关注，起到了民间构建与国家构建互动回应、反思平衡的作用。尽管这种作用仍是局部的、有限的，其意义却是深远的。

四是参与形式受到资源的制约。从某种意义上讲，传统的中央集权管理体制塑造了一个总体性社会。一方面，它使得国家政权阈限延伸到社会底层，社会组织的生存活动空间自然与之互溶依存；另一方面，社会参与也呈现一种以执政党为主导的、以政治动员和全社会动员为基础的分层次运作机制。这固然提高了社会一体化效应，却也意味着社会参与是体制性的、封闭性的、泛政治化的和精英性的。这种制度环境的历史惯性，必然会对社会组织的参与形式产生很大的影响。而且，官办组织和草根组织自身拥有的资源不同，也决定了其参与形式的不同。官办组织走国家与社会结合型的路径，草根组织由于没有这种结合的资源，基本上采取了体制外的、立足社会的路径。

总体而言，在复杂的制度环境下，中国的社会组织通过与政府的合作博弈、扎根底层的社会动员、迂回曲折的灵活参与、热心公益的形象展示等，不断开掘、拓展自身的活动能力与空间，在权利维护、价值倡导、促进公平、增进和谐、强化自律秩序等方面发挥了重要的民间构建作用，同时，也对政府监管和公共政策产生了一定的回应压力和反向塑造。改革传统监管体制，走向“社会合作主义”并塑造发展型制度环境，或正是大势所趋。

（二）治理能力与角色认知

近四十年来，我国社会组织获得了飞速发展，但也存在着不容忽视的尴尬问题。

其一，独立性不足。以普遍被看重的行业协会为例，虽然它们已被置于体制之外，但无论是作为行政改革的分流蓄水池，或是权力退出机制的缓冲阀，它们都无法独立于国家，相反，其职位录用深受政府管控，形成国家的积极嵌入。行业协会作为非物质生产部门，因其资源稀缺而对外界资源具有高度的依赖性，这又反过来使行业协会主动地要求国家嵌入，特别是在编制资源和办公地点、经费等物质支持上。“如果他们完全依赖政府的财政支持，即使强大的、自治的组织，也会逐渐变得虚弱下去”，^[27]这样，无论是国家的主动嵌入，还是协会主动要求国家嵌入，全国性行业协会并没有完整地享有排他性的控制权，协会与国家分享部分控制权的客观现实意味着机构独立性的残缺或丧失。这必然会导致行业

[26] 参见陶传进、王名：《中国民间组织研究报告》，载吴玉章主编：《社会团体的法律问题》，社会科学文献出版社2004年版，第386页。

[27] 前引〔19〕，费希尔书，第124页。

协会的社会合法性不足,组织功能上也有缺陷。实践中,行业协会生存状态好坏不一,其中有“1/3 难以维持,1/3 勉强维持,1/3 发展比较好”。^[28]

其二,治理能力不足。仍以行业协会、商会为例,它们不仅面临着资金、人才“自我造血”功能的先天不足,也面临着长期存在的两种治理失范的风险:一是其内部治理受到外部行政力量的干扰或影响,包括建制化的体制依附和基于官员身份的人身关系依附;二是“精英治理”现象,即行业协会、商会的负责人凭借自身的资源、威望或者人格魅力,主导其内部事务的决策和执行,以及依附于行业龙头企业、大企业或者“内部”企业——被借行业协会、商会之“壳”兴办的企业所架空。^[29]与此类似,一些草根社会组织创始人也将该组织当成自己个人的私产,独断专行,有的理事缺乏对社会组织使命的深入理解和认同,不愿意投入时间,没有发挥理事会应有的决策与监督功能。^[30]

其三,角色认知不足。社会组织发展也受制于其自身的认知水平,无论官办、民办还是官民合办的社会组织,都不同程度地存在这一问题。其中,近年来迅猛发展、前景看好的数百万草根组织,对自身认知不清、定位不准等问题则更为明显。这主要包括:一些草根民间组织缺乏使命感,甚至打着非营利的旗号为个人牟利;缺乏理想与抱负,缺乏对行业的引领、对社会责任的担当,甚至成为一些非公募基金会或者企业避税的工具;缺乏合作精神,社会认同水平和合作能力不足;等等。^[31]这些角色认知障碍,既与其自身资源条件和发展水平有关,也与其缺少合法性、身处政府规制之外又缺少社会监督有关。这无疑会严重影响它们功能的发挥和未来发展的前景。

(三) 公信困境与中介腐败

在各类社会组织中,几乎都存在着从业人员年龄结构老化、行业代表性不强、服务会员功能弱化、自身活力不足、难以形成行业共同自律行动和进行整体号召动员等“通病”。尤其是某些协会“官气”渐盛,行业自主及自治性特点日益淡化,难以正常发挥其自我规制和业内行为引导的作用,甚至形成了一定的公信危机。

首先是“代表”困境。例如,在2012年11月酒鬼酒因媒体报道而深陷“塑化剂丑闻”之时,业内人士就曾质疑中国酒业协会对其所属企业帮了“倒忙”。不少消费者埋怨,该协会没有及时将其向公众公布,沉默时间长达17个月。究竟“代表谁”的纠结和尴尬,使协会对酒企和消费者“两边得罪”。^[32]又如,2016年5月27日中国乳制品工业协会发布报告称,国产乳制品正处在“历史最好时期”,而6月12日国家的食品安全风险监测即发现伊利全优乳粉产品的汞含量异常。这些行业协会尽管维护了企业、行业的眼前利益,但因其对行业内出现的各种丑闻的辩解、袒护,非但不能起到监管和自律的作用,反而纵容一些企业投机取巧、损害公共利益,最终必将损害整体信誉、影响行业的长远发展,^[33]也因没能担当起应有的社会责任而损害其社会公信力。

[28] 龙宁丽:《经济社团治理现代化:现状、问题及变革——一项基于全国性行业协会的实证分析》,《中共宁波市委党校学报》2014年第6期,第92页,第94页。

[29] 宋晓清:《谨防行业协会商会与行政机关脱钩过程中的三种风险》,《中国社会组织》2015年第21期,第30页。

[30] 参见邓国胜:《中国草根NGO发展的现状与障碍》,《社会观察》2010年第5期,第13页。

[31] 同上。

[32] 参见孙卫涛:《中酒协隐瞒塑化剂问题 企业消费者两边得罪》,《投资者报》2012年第48期。

[33] 同上。



其次是“骚扰”难题。有些协会为了收取会费和谋取收入,利用自身的“行政化”身份,不断在会费、会议、考察等方面对企业实施“骚扰”。如跨地区、跨行业的国有大型企业集团——安徽四方集团公司动用涉及“至少9个部门的人力物力”,应付各式各样“协会骚扰”,每年耗资几十万元;2006年公司加入的协会,就达19家之多。^[34]

再次是参与腐败。在我国商业贿赂、政府官员寻租等日益严重的贿赂腐败链条中,社会中介参与和引发寻租腐败的状况呈现加重趋势,主要包括三大行为:行贿、洗钱、侵吞国有资产,而政社不分、行政干预为一些中介组织参与腐败提供了条件。^[35]这些问题的存在,严重消减了社会组织的社会公信力和动员能力,使其难以提供更多更好的公共服务,难以获得社会各方的认可与支持。虽然这并不是主流,却对之不可忽视,亟需制度变革和体制完善来加以解决。

(四) 传统的路径依赖

与政府、市场一样,社会组织也存在一定程度的“失灵”问题,即使在西方发达国家,其社会组织也存在官僚化、商业化和脱离公众的危险。

传统中国的结社习惯与自治精神明显不足,以国家控制来实现社会秩序的传统由来已久。当下国家对社会组织的“枢纽化”管理,依然是出于令其服从服务于党政中心工作的考虑,力图通过“以社会管社会”的方式来更好地维持秩序,因而要在人、财、物和制度设计等各方面来规划、控制社会组织。而相当数量的社会组织也出于风险、收益和绩效考虑,往往主动靠近政府,热衷于向政府要编制、要经费、争职能,以寻求其合法性、权威性,^[36]甚至还可能凭借其官方化角色“搭车”寻租。这种互动合作“实际上并不是非理性的,而是为了在这种社会环境下生存的惟一理性策略”,^[37]是一种相互强化的“路径依赖”过程。那些不能获得政府支持和政策惠顾的“非主流”社会组织(如大量草根组织),则只能借助社会力量来谋取经费和发展资源,并受制于资助方的影响,个别组织甚至还直接从事违规牟利活动。这就导致社会组织缺少足够的社会性、自主性、公信力和治理能力,它们对国家构建过程的互动回应、反思能力和参与空间都严重不足,而在自律秩序等方面的社会自我构建上也步履艰难,其推进法治进程的功能自然就大大受限。

三、社会组织“不在场”对法治建设的影响

法治建设不可能是来自于国家的或者民间的单边行动,而是立足于国家与社会的多元力量的互动推进过程。社会组织无疑是其中一支非常重要的法治建设力量。如果社会组织不能积极发挥作用,必将影响法治建设实践进程。

(一) 安定性框架下的功能性“不在场”

这里所说的社会组织“不在场”,并非没有社会组织的存在,而是指社会组织尽管数量很大、种类繁多,却未能在法治建设进程中展现其应有的角色担当,实际上是一种功能性

[34] 参见赵民望:《谁来治理“协会骚扰”》,《中华工商时报》2006年11月10日01版。

[35] 滕兴才:《警惕:一些中介组织正在沦为腐败中介》,《政府法制》2009年第8期,第30页以下。

[36] 参见翟鸿祥:《行业协会发展理论与实践》,经济科学出版社2003年版,第215页。

[37] [美] 罗伯特·D. 帕特南:《使民主运转起来》,王列等译,江西人民出版社2001年版,第208页。

的“不在场”。

1. 安定性的总体框架模式。我国对社会组织实行免于登记、直接登记和双重登记管理的类型化、等差性制度设定。这种安排无疑包含着体制化、政治可靠性和秩序风险性的考量,即“免于登记”是对三十多个“体制化”或“半体制化”社会组织的豁免,“直接登记”是对商业、科技、公益、服务性社会组织所赋有的安定和民生保障功能的肯定,其余双重管理体制下的社会组织,则实行前置审查和登记审查。近年来,很多地方又通过枢纽型社会组织的方式,对社会组织进行行政性构建和塑造,以使社会组织的发展能够服从国家规划秩序的整体安排。这样,社会组织的功能和作用就基本被纳入了既推进政社分开又服从体制的总体性、安定性的规制框架,主要用来满足执政战略和维护稳定的需要。然而,这一安排却限制了社会组织的自主性、代表性和治理能力的获得与提升,并导致社会公众原本对社会组织认可度远低于政府的状况进一步固化。社会组织既要面对上述发展生态,又有基于社会发展需要和民众诉求所带来的新生动力,这就使它们不得不与政府在双向塑造中磨合成长,形成国家构建主导与社会组织偏行脱控的复杂博弈状态,并进而加剧政府与社会组织的内在张力,健康的社会治理和运行机制难以形成。

2. 官民的良性互动和反思平衡难以形成。出于转型期维护权威、秩序和稳定的考虑,政府让社会组织担当起桥梁和助手的角色,社会组织也就成为政府分散转型压力、落实方针政策、实现社会控制的“雇员”,而不是合作治理的“伙伴”,^[38]这无疑会加剧社会组织的行政化、官僚化、异己化。那些未能直接纳入其“桥梁和助手”系列的大量社会组织,则在体制外游走,与枢纽型社会组织保持着若即若离的关系,或者没有关系。而只要它们不给政府“惹麻烦”,政府就会对其持一种默认或“无视”的态度。然而,由于国家建构策略下的政府监管模式,倾向于“政治正确”和维护稳定的定位,基于社会组织自身属性和民众现实需求的规制目标就会相应降低。于是,政府就会着力在监管规则和政策导向上进行“服务大局”的构建,而在关乎社会组织独立性和业务能力的治理结构、社会动员、公信力和制度保障等问题上,则关注不够、着力不多,其实质是以“国家方式”来构建社会,而不是以“社会方式”来构建社会。这种导向与职能的扭曲,使得政府监管很难回应日益增长的社会化、多元化、自治化的治理诉求,也会导致社会组织发展出现一种类似“扶不起来的阿斗”之困局——难以自主独立,又能力不足,以致彼此相互强化。这样,无论体制内还是体制外,无论“桥梁、助手”还是草根组织,都依赖于国家构建的总体框架而存在和发展。它们要么主动靠近政府以争获资源,而不是在服务性、代表性和公信力上下功夫;^[39]要么在政府默认的“红线”内,谨慎拓展自己的“飞地”,而少有承担社会使命和责任。在这一境况下,它们首先考虑的是国家认可的合法性和自身的安全度,根本上是一种“顺应体制性安排而非回应社会诉求”的生存发展逻辑。尽管它们生长于社会,却没能完全扎根于社会,治理能力和角色认知也出现了障碍和偏差,从而无形中消减了社会组织作为社会建设主力军和自主秩序构建者的角色。这样,它们既难以有效实现对国家构建的互动参与和反思平衡,也不能充分发挥其在转型期的民间治理和社会秩序的自我构建功能,

[38] 参见鲁篱:《行业协会经济自治权研究》,法律出版社2003年版,第233页以下。

[39] 参见前引[36],翟鸿祥书,第215页。



社会中的多元权利主张和复杂利益冲突也很难得到真正的规制和化解,从而危及国家治理的合法性基础、民主法治进程和社会和谐稳定。

3. 加剧了国家构建主义法治的倾向。国家构建策略及其安定性规制框架,使社会组织既难以成为社会各方利益的真正代表,也缺少分解制衡权力、维护保障权利、推进多元治理的能力,难以更自主、更有效地进行民间构建行动,导致了社会组织功能性“不在场”情况的发生。如果社会组织这一来源于社会、代表社会、服务于社会的重要法治推进力量“不在场”,法治进程就只能更多地依靠国家规划设计来构建了。当下中国法治进程中所出现的规划主义、普遍主义、工具主义、法条主义等问题,跟这一因素有直接关系。力图通过国家规划和设计来塑造符合执政理念与发展蓝图的秩序目标,也许是必要的,但在全面推进依法治国和实现国家治理能力现代化的时代背景下,如果没有把权力关进制度的笼子里,那么这种国家构建就很可能成为“一项傲慢且无效的工作”,^[40]而“国家—社会的分权不充分,人民缺乏参与公共事务的渠道,缺乏对政府的问责手段”,“对于地方政府滥用权力、与民争利的行为,人民要么忍气吞声,要么走上街头抗议”的情况就可能成为现实。^[41]这种状况无疑会严重制约法治中国战略的有效实施,亟需予以变革和改进。

(二) 社会组织“不在场”对法治建设的深层影响

法治进程中社会组织的“不在场”,并不是法治建设力量多少的简单问题,而是涉及法治建设基础、结构和动力的重大问题。它所产生的不良后果,已成为当下中国法治进程不可忽视的重要障碍。

其一,“两极结构”的怪圈。近代以来社会组织兴起的一个重大功效,就是能够形成一种横亘在国家和私域之间,既能够抵御公权滥用又能限制私权任性的缓冲堤坝,“在纵横四溢的个人利己主义和国家的巨大且又具有威慑性的力量之间,它们占据中间地位”,^[42]发挥重要的矛盾缓冲、桥梁纽带和安全阀作用。而传统中国则是一种国家高度统摄、控制社会的状态,它旨在形成服从服务于国家(皇权统治)需要的整体主义秩序,展现民间力量的结社活动必然要受到严格控制。尽管传统中国也有私人空间和较为活跃的社会生活,却呈现出个体的原子化和社会的无组织性,“社会不具有表达自己利益诉求和参与公共事务决策的能力”,^[43]也就形成了强大国家直接面对分散个体的“两极结构”,成为“要么一盘散沙、要么集权卷土重来”这一历史怪圈的重要遗传基因。

改革开放后,“小政府、大社会”的格局日渐形成,社会组织也迅速崛起,形成了走出“两极结构”的重要契机。然而,国家对社会组织的建构策略则在一定程度上阻滞了这一进程。尽管市场经济使得社会从国家管制中获得了巨大释放,但个人和企业都无法超越其自身局限,难以赋有社会组织那样的公共属性、利益代表和参与功能,而社会组织却又因身受国家安定性规制框架制约、自身的动员和治理能力有限以及公信力不足等现实因素,难以发挥其应有的功能。这样,社会在实质上仍带有较重的分散性和“无组织”状态,依然存在着“两极结构”的问题。

[40] 前引[2],布林克霍夫书,第39页。

[41] 郑永年:《中国模式——经验与挑战》,中信出版集团2016年版,第168页。

[42] [美]丹尼尔·贝尔:《资本主义文化矛盾》,赵一凡等译,生活·读书·新知三联书店1989年版,第319页。

[43] 葛洪义:《中国地方治理与法治发展的关系》,《新华日报》2016年4月29日018版。

缺少社会组织所能有效提供的中间缓冲带,就难免形成一种政府与“无组织”的社会及其分散公众的直接面对格局,促发权力与权利的“赤膊”对弈。其好处在于,民众难以形成组织化的“对抗”力量,使得政府容易实施社会管控,平息突发事件,实现安定秩序;不足则在于,政府与分散的公众之间缺少有效的组织化沟通机制,误解、矛盾和风险必然会大大增加,也难以对可能的民粹情绪和大众行为实施有效的预警和控制。在面对公权力扩张和肆意时,分散的私权利往往是无力的,也显得十分脆弱和无奈;而在面对私权利滥用和任性时,公权力则习惯于通过强力来予以防范和压制,以图一时平安,但长此以往,则容易留下危及秩序的祸根。在公共政策和社会治理上,因缺少组织化的诉求代表和参与监督,多元群体利益和权利就难以得到有效保障和实现;而一旦矛盾升级为群体事件,则因缺少理性对话的中介组织力量,常常呈现出非理性的公权暴力与“乌合之众”的群氓暴戾之间的对抗消长。可见,“两极结构”怪圈的最大问题,就是缺少社会组织这一社会自我管理的秩序平衡力量,而实践中出现的要么强权控制、要么混乱无序,“一统即死、一放即乱”的恶性循环与难题,很大程度上便是根源于此。这样,官方和民间存在诸多的误解和矛盾,导致舆论撕裂,社会流动性差,公众对社会事件的有效参与不够,社会的凝聚力和向心力不足,也就在所难免了。这必然严重制约中国的法治建设进程。

其二,汲取性机制的风险。当下中国法治进程中社会组织的“不在场”,很大程度上源于国家强力主导与民间力量脆弱的互为因果和相互强化。它加剧了“强国家、弱社会”格局的固化和国家构建主义法治进路的形成,也容易产生汲取性机制的社会风险。

汲取性机制在历史上是比较普遍的,在当代转型国家中也并不少见。汲取性机制“有一个强有力的逻辑:它们能够产生某种有限繁荣,同时将有限繁荣产生的财富分配到少数精英手中”,^[44]斗争和不稳定构成了汲取性制度的固有特征。产生汲取性机制的一个重要原因,就是公众参与机制不健全、社会组织功能发挥不充分,导致多元利益群体诉求不能得以有效表达和保护,公权力得不到有效制约和控制,权贵阶层把控公共事物和社会分配,社会发展和民众创造所产生的利益和权利被适时汲取就是自然而然的事情了。

在我国,改革开放后形成了“先富带后富”的发展逻辑,它在促进经济增长、民主法治和社会进步等方面取得巨大成就的同时,也带来了一些亟待解决的严重问题,产生了汲取性机制的某些征兆,而这与民间组织的“不在场”密切相关。中国近四十年的高速增长,是一种以“强国家、弱社会”为主导的发展方式。一方面,尽管各类社会组织迅速崛起,但在国家的整体主义构建策略之下,其成长空间和能力有限;另一方面,贫富差距、城乡差距和东西差距巨大,阶层利益分化、利益固化和等差身份严重,价值撕裂加剧、社会共识不足、民生保障不力,导致日常生活中汲取性问题不时发生。尽管中国的经济发展奇迹创造了巨额财富和无限机会,但底层民众并没有足够的获得感。换句话说,恰是社会组织不发达或者功能不健全,难以有效表达诉求、实现民主参与和社会自治,导致一些群体缺少在公共事务中的组织代言和话语权,其基本权益也缺少组织化、理性化的有力保护。城乡、阶层、地区发展在局部的不平衡,以及以牺牲一部分人利益为代价来谋取另一部人利

[44] [美] 德隆·阿西莫格鲁、詹姆斯·A. 鲁滨逊:《国家为什么会失败》,李增刚译,湖南科学技术出版社2015年版,第107页。

益的具体问题和个案,就常常被放大,甚至演变成无组织的、分散公众的群体性事件。同时,由于缺少社会组织代表不同群体权益和诉求而形成的有力监督和制约,加剧了一些地方政府不受约束的肆意剥夺和政绩化、汲取式发展,进而强化了公权腐败、贫富分化和社会结构失衡,加剧了社会秩序风险。

从世界范围来看,“现在国家经济和政治失败的解决方案是把他们的汲取性制度转变成包容性制度”。^[45]当前,党和国家也适时提出了“共建共享”的发展理念,力图对发展过程中出现的汲取性问题予以纠偏,“构建全民共建共享的社会治理格局”。^[46]这就需要强化各种社会组织功能,把属于不同利益群体的人们有效地、理性地组织起来,在制约公权力、抗衡权贵阶层、平衡不同群体利益过程中,保护自身的权益和拓展发展空间,进而“重建国家与社会互构机制的载体,使全体社会成员都有与国家对话的机会”,^[47]从汲取性机制走向多元平等、公正自由、共建共享的包容性机制,更好地推进法治中国建设。

其三,自律秩序的乏力。随着科技革命、全球化加速和网络时代的到来,“旧的秩序被颠覆,新的秩序得以建立”,而“在新的经济秩序里机遇与陷阱并存”,^[48]这无疑就增加了太多的不确定性和风险性。在这一过程中,国家与社会的各方力量携手合作应对各种复杂问题与风险危机,就成为一种必然的选择,特别是充分发挥社会组织这一自主自治力量尤为关键。一方面,分散的个人、企业或者其他社会单位,都因自身属性和局限而难以发挥构建自主自律秩序的作用,恰恰是社会组织才能有效填补相应的秩序构建空间,担负起行业自律、自主管理和互助服务等诸多责任,通过其赋权实践来“消除权力与资源分配上不断产生的分割与不平等”,^[49]抑制汲取性机制的生成和发展。另一方面,市场经济的发展必然要减少由外部来规划安排的“人造的秩序”,会大大加强内部自我生成的“增长的秩序”,^[50]而且,很多人们认为正确的东西,往往都未能“与政策的‘主要建筑师’们的计划相一致”。^[51]任何社会的发展,实际上都是“一个体系变革的过程,这涉及一个社会的各成员是如何相互合作、携手共进的”。^[52]充分发挥社会组织对不同阶层和利益群体的动员能力和诉求表达机制,促进它们对自主自律秩序的构建功能,十分重要而关键。

对当下中国而言,其主导方向是在负面清单、权力清单和“法不禁止即自由”的原则下,减少国家干预、释放社会自主空间,进而实现国家治理能力现代化和治理法治化。在政府的规划管理退出后,如何防止无政府的“自然状态”,充分发挥社会组织所赋有的社会秩序自我构建功能,就成为亟待解决的问题。然而,我国社会组织当前面临着以下困境:国家构建策略限制了社会组织对自主自律秩序的构建能力与构建空间,使其缺少足够的民间建构条件和机会;国家构建策略和现实环境抑制了社会组织的治理能力提升;受制于国

[45] 前引[44],阿西莫格鲁等书,第299页。

[46] 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,《人民日报》2015年11月4日01版。

[47] 谢舜、盛志宏:《社会政策过程中公众参与角色的变迁及其社会意义》,《江汉论坛》2012年第8期,第9页。

[48] [美]凯文·凯利:《新经济新规则——网络经济的十种策略》,刘仲涛等译,电子工业出版社2014年版,“前言”。

[49] [英]Robert Adams:《赋权、参与和社会工作》,汪冬译,华东理工大学出版社2013年版,第248页。

[50] [英]弗里德利希·冯·哈耶克:《法律、立法与自由》第1卷,邓正来等译,中国大百科全书出版社2000年版,第55页。

[51] [美]诺姆·乔姆斯基:《新自由主义与全球秩序》,徐海铭等译,江苏人民出版社2000年版,第26页。

[52] [美]赛斯·D.卡普兰:《修复脆弱的国家:发展的新范例》,颜琳译,民主与建设出版社2015年版,第16页。

家构建策略的政治方向指引,社会组织也缺少足够的社会使命和担当。这就需要深化社会组织体制改革和加大制度建设,从宪法制度下的公共权力安排、公共生活的治理之道、公民的公共理性、国家和社会权力(权利)的界限来看待社会组织问题,并作出相应制度安排。^[53]

其四,国家构建与民间构建的错位。由于诸多历史和现实的制约因素,国家与社会关系一直未能形成稳定有效的良性互动关系,更多时候呈现出一种强国家与弱社会、一体化控制与破碎化状态的张力关系。这种情况下,容易形成国家对社会的强势构建倾向,也容易出现社会对国家的消极规避、甚至做出“破窗”性挑战和反向博弈。^[54]“上有政策、下有对策”就是这种张力在一定意义和程度上的反映。更为重要的是,由社会组织“不在场”导致的功能缺失和作用机制乏力,会加剧国家构建与民间构建的某种错位。

一是公共政策和治理变革往往不是通过民主协商的程式化、制度化方式得以演进,而是伴随着群体性事件、重大舆情案件、暴戾事件和强力维稳的冲突与压力而前行。如多地PX项目、拆迁补偿等方面发生的重大舆情事件,其中很重要的原因之一,就是缺少作为其真正利益代表的社会组织来进行常态化维权和参与理性谈判,导致权力制约、权利保障和秩序维护不力,形成了肆意的公权暴力与分散的民众暴戾之间的负向博弈和恶性循环。

二是国家承认与社会认同出现断裂,有效的话语构建与价值共识变得步履艰难。由于社会组织在公共决策和制度建设上的缺位,多元利益群体缺乏有效的、可靠的组织化诉求表达渠道,协商民主机制也不够完善,因此,国家对民众诉求的承认和民众对公共政策及制度变革的认同,就不能有效地对接耦合,而在缺少社会组织有效参与的组织化、理性化、常态化的协商对话机制情况下,就出现了官方和民间相互隔裂的“两个舆论场”。^[55]在一些地方的重大舆情事件中,甚至出现了“逢官必反”、“逢民必控”的极端情况,这会助长价值撕裂和“乌托邦精神”、“无政府主义”、“民粹主义”等思潮的悄然泛起。^[56]如何打通两个舆论场,形成最大公约数和理性的价值共识,以官民“共建共享”精神来构建为中国改革发展提供方向性引导的主流价值观,已成为需要解决的迫切问题。

三是过强的国家构建导向加剧了社会组织的“双重使命”失衡,使得社会治理面临着“丛林秩序”的风险。正常情况下,社会组织既承担着代表本行业、本群体、本领域利益的责任与使命,也承担着推进本行业(群体、领域)自律、协调与其他行业(群体、领域)之间矛盾和维护公共秩序的社会责任与使命,它应该具有法律合法性,也必须获得公众认同而获得社会公信力。然而,多年来我们一直保持着社会组织发展的“政治正确”导向和管制性策略。尽管这些举措有其关乎安定性、特色性的合理性和必要性考量,但过强的“政治正确”导向难免会导致社会组织服膺于体制框架的政治合法性和法律合法性,只要获得体制认可就可以成为本行业(群体、领域)的当然代表,而不一定要通过公众认可来赢得公信力和合法性。这样,它们会在服从“政治正确”性和政府监管上下功夫,也会在本行业(群体、领域)的一己利益上作出努力,却在社会公共利益和公信力上缺少动力。

[53] 参见刘培峰:《结社自由及其限制》,社会科学文献出版社2007年版,第314页以下。

[54] 参见[美]乔治·凯琳·凯瑟琳·科尔斯:《破窗效应——失序世界的关键影响力》,陈智文译,生活·读书·新知三联书店2014年版,第23页。

[55] 邢彦辉:《两个“舆论场”的张力与融合》,《中国记者》2012年第12期,第101页。

[56] 参见马立诚:《当代中国八种社会思潮》,社会科学文献出版社2012年版。

四是国家对社会组织功能的类型化引导和控制,使得国家构建与民间构建在功能和领域上出现了明显的不对称。目前的社会组织管理体制、规范和策略,采取了区别身份等级、设定不同门槛以及构建枢纽型社会组织等举措,其中有些可能是过渡性的权宜之计,有些可能出于转型期稳定的需要,但其中一个明显的倾向,是对体制性团体以及行业管理、科技发展、公益慈善和城乡社区服务等具有“正能量”或者“中性”、“辅助性”功能的社会组织,予以积极促进和发展,而对于社会科学、观念倡导、权益保护等具有民主参与和监督功能的社会组织,则仍需按照双重管理体制来从严规制。这就会使民间构建过程中缺少民主参与和监督的成分与机制,社会组织在参与领域上“从边缘迈向中心”的步伐仍会很艰难,导致国家构建与民间构建的不对称和严重失衡,不利于上情下达、下情上达和多元协商,不利于实现国家治理能力现代化和建立治理法治化秩序。

四、社会组织使命与共建共享型法治道路

中共十八届四中全会之后,在法治建设中适时改变国家构建主义策略,充分发挥社会组织的民间治理功能,携手推进国家与民间的双向构建和共建共享,成为大势所趋。

(一)“共建共享”展现了当代世界的发展趋势

从某种意义上讲,国家产生和发展的进程就是一种国家构建的进程,而现代国家制度更是离不开国家构建的作用。然而,“国家构建并不是一个预先设定或单向的进程,所以,地方实验和接受是国家构建得以可能的关键性因素”,^[57]它无论如何不能单凭自己的规划和命令来完成,而必须以社会参与和公众认同为基础和前提。因此,国家与社会的结构状态、互动方式、关系机制等,就不仅决定着国家构建的成败,也决定着民族发展的方向和未来。纵观近代发展史不难看到,自由资本主义阶段是“小政府、大社会”,垄断资本主义阶段是“大政府、小社会”,福利国家阶段是“弱政府、强社会”,全球资本主义阶段是“中政府、中社会”或者“强政府、强社会”。这一演进变革的逻辑背后,是“国家对社会之必要,社会对国家的制约,以公共权力为根基的国家干预与以个人权利为根基的社会自治之间的张力,始终在国家与社会关系的建构中发挥着作用”。^[58]

随着全球化进程加快和网络时代的到来,世界面临着前所未有的巨大机遇和挑战。特别是国家与社会关系,已不再是所谓“二元对立”或者“第三条道路”所能应对的。曾经创造了拉美国家繁荣的“华盛顿共识”,也并未实现其从汲取性制度“走向包容性经济制度的进步”,^[59]而“北京共识”所提供的“中国模式”和“中国方案”则日渐产生影响。绝大多数发展中国家的国家能力堪忧,甚至形成了“弱国家”与“碎片化社会控制”的恶性循环,^[60]而这些“软弱无能国家或失败国家已成为当今世界许多严重问题(从贫困、艾滋病、毒品到恐怖主义)的根源”。^[61]但是,过度集权的强国家无疑会形成汲取性制度和体

[57] 前引[2],布林克霍夫书,第58页,第27页。

[58] 庞金友:《现代西方国家与社会关系理论》,中国政法大学出版社2006年版,第157页,第151页。

[59] 前引[44],阿西莫格鲁等书,第323页。

[60] [美]乔尔·S.米格代尔:《强国家与弱社会——第三世界的国家社会关系及国家能力》,张长东等译,凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社2009年版,第289页。

[61] 前引[1],福山书,“序”,第1页。

制，宰制和侵蚀社会权利与自由空间，造成积贫积弱的弱社会，社会动荡和危机就在所难免。这两种极端倾向，都“可以追溯到社会凝聚力以及一整套共享的、有生产力的制度的缺失”。^{〔62〕}因此，只有强国家、强社会的双强互动构架，才是应对当今全球化和信息革命所带来的多元化、破碎化、原子化、自由化等复杂多变问题的有效模式，而转向注重社会力量参与、进行共建共享型的包容性制度重建，也就成为当下的必然选择。其中，国家通过全局发展的方向引导、国家重点领域的干预调节、基本民生的人权保障等，提供平等多元、自由公正的价值指引和秩序校正，而更大范围、更日常化的社会秩序，则是由多元社会主体、特别是社会组织来塑造和维护的。只有建立起国家与社会的双强互动构架，才能促进二者的双向构建、共建共享和良性运行，国家治理能力现代化和社会治理法治化也才能真正成为现实。

（二）社会组织：共建共享型法治的重要载体和支撑力量

推进双强互动构架，塑造共建共享型法治，就必须摒弃以往的国家构建主义策略，扭转社会组织功能性“不在场”的不良局面，推动其积极发挥民间治理功能和民间构建作用，进而以社会组织为支撑来打造共建共享型法治建设的社会动力机制。这也是迈向中国特色共建共享型法治道路的重要探索和伟大实践。

首先，增进民主立法，构建包容性机制，实现制度建设上的共建共享。完善的规范体系是法治国家建设的根本前提，而立法民主化则是实现制度上共建共享的基本途径。这就要求革除部门立法固化和地方保护主义法律化，切实让不同阶层的民众能够享有立法上的话语权和利益表达渠道，使法律制度建立在真正的社会共识和“最大公约数”的基础上，增进其民主性、合理性与合法性。社会组织是不同阶层和不同群体的利益代表，它们要比个人更有理性、智慧、影响力和动员能力，也更能形成机制化的民主协商和立法参与形式。更重要的是，恢复法治进程中社会组织的功能性“在场”状态，无疑是走出“两极结构”怪圈、抑制汲取性机制，实现国家构建与民间构建之间良性互动、反思平衡的重要途径。中国的复兴是“伴随着摆脱高度集中的经济制度并转向更包容的经济制度而来的”。^{〔63〕}近年来，在公益慈善、环保医疗、社会救助、民权保障等方面的立法过程中，社会组织参与立法的能力和質量越来越高，大大提升了不同群体诉求和利益在立法博弈中的分量，反映了立法上的更多民主共识。当然，我们还需要推进人民代表大会制度改革，适时增加人大代表中的社会组织界别，以使社会组织能够有更多、更有效的体制内和体制外表达渠道；也需要从体制和制度上更多地鼓励和支持社会组织以各种形式来参与民主立法，推进其在国家构建过程中充分发挥互动参与和反思修正功能，促进国家与社会以及多元社会力量在制度建设上的共建共享，为共建共享型法治提供制度支撑和根本保障。

其次，塑造自律秩序，实现国家与社会治理上的共建共享。从国家构建走向共建共享，一个突出的问题是，政府管理退出后，市场自由和社会自主秩序不能陷于混乱，而必须由新的组织力量来承接自律管理职责，填补这一秩序构建空间，以防止“一统即死、一放即乱”的怪圈重现。无论从全球经验来看，还是从中国实际出发，这一角色都非社会组织莫

〔62〕 前引〔52〕，卡普兰书，第68页。

〔63〕 前引〔44〕，阿西莫格鲁等书，第313页。

属。社会组织应该立足本群体利益、社会公信和公共责任,代表其所属群体的利益和诉求,与政府进行对话协商和互动合作,与其他利益群体进行利益协调和沟通平衡,并对所属成员进行必要的自我服务和自律规制,在各个领域中践行共建共享理念,发挥其制约公权力、保障私权利和化解矛盾冲突的重要作用,平衡地承担其应有的双重使命,努力构建与国家规划秩序相对应、相契合、相平衡的民间自主秩序。这不仅能够有效促进国家构建与民间构建的互动平衡,也必会成为推进共建共享型法治秩序的支撑和推进力量。

再次,塑造多领域、多层次治理机制,推进政府决策的民主性与合法性,实现公共政策上的共建共享。多领域多层次法治化治理,是法治中国建设的重要根基,需要建立和拓展吸纳民众参与的治理场域、平台、机制和途径,切实保障基层治理法治化中的民众参与机会和权利,让民众形成应有的在场感、共建感。这必然要求大力发挥社会组织的代表角色、动员能力和参与功能,改变对社会组织进行身份等差设定、类型化的功能引导控制等不当制度设计,使得社会组织无论是在区域治理、社区治理、乡镇治理、乡村治理中,还是在行业治理、网络治理、环境治理、社会治安综合治理、食品安全治理中,都能代表不同利益群体来积极参与治理过程,表达各自的利益关切、主张各自的权利,并分别在政府、市场主体和多元群体之间进行程式化、制度化的对话协商,发挥社会组织这一民间力量的对话与构建作用,促进国家构建与民间构建在功能和领域上的对称与平衡。因此,需要以政府、市场和社会“三元”框架及其运行规律为现实基础和逻辑起点,通过包容、吸纳和整合社会组织所代表的不同群体的呼声与诉求来形成重叠性共识,来切实改革和塑造政府的民主决策机制,提升公共政策合理性与合法性,增强政府服务社会、解决复杂问题和应对风险危机的能力。这就使得国家构建过程中嵌入了民间构建的互动反思机制,不仅能够实现政府决策与民意诉求的互动协商和彼此塑造,也能够促进诸多利益群体之间利益诉求与现实权利的博弈平衡,最终形成切实的多层次多领域民间治理机制,以实现国家与社会之间双向构建、互动平衡、共建共享的治理格局和法治秩序。

最后,促进“承认”与“认同”的协调包容,形成全社会的法治共识,实现价值观上的共建共享。改革开放后,随着市场经济的纵深发展和网络时代的到来,传统价值观日益受到新价值观的挑战,并对当下全面推进依法治国的战略实施产生不利影响。对此,单向的官方话语构建,采取简单的强力灌输的办法,都难免会加剧价值撕裂和“两个舆论场”的内在张力。因此,亟需深入贯彻党和国家关于打造“共建共享治理格局”的战略部署,采取开放包容、吸纳引导的方式,让国家和社会力量携起手来共建核心价值观,打通并弥合“两个舆论场”,形成价值共识和法治共识。其中,社会组织必将发挥重要的积极作用。一方面,面对日益多元化的社会分层和群体分化,社会组织能够代表各自所属的不同利益群体,积极参与专题协商、对口协商、界别协商和基层民主协商,促使政府按照法治精神与原则来对不同群体的价值主张和合理诉求予以有效承认并公共政策化,也能够通过社会组织的自治管理和民间秩序构建,来促进所属群体成员对全社会的价值共识与法治精神予以认同。另一方面,社会组织能够通过其业务活动,发挥“对其成员的行为导引、规则约束、权益维护作用”;^[64]通过其组织化的理性协商机制和自律精神,来消解本群体中可能

[64] 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,《人民日报》2014年10月29日01版。



的“乌托邦精神”、“无政府主义”、“民粹主义”情绪，从而有助于形成共建共享的法治精神与原则，推动治理法治化秩序的形成。

（三）提升社会组织的民间构建能力，塑造共建共享型法治秩序

虽然社会组织将成为共建共享型法治秩序的重要支撑和推进力量，但由于历史传统、现有体制和现实国情等因素的制约和影响，要真正发挥社会组织作用，形成共建共享的治理格局和法治秩序，尚需更多实践探索和制度创新。

其一，确立共建共享的治理法治化思维。由于中国的秩序构建更多是由国家主导，而缺少社会组织自主治理的传统，发挥社会组织对共建共享治理格局的重要使命和作用，就需要在全社会摒弃传统的从上到下、单一强力的国家构建观念，确立国家与社会之间的双向构建、互动平衡和共建共享的治理法治化思维。对政府而言，要知道“社会组织能否发挥正向作用关键是看党和政府能否进行正面引导。社会组织管理体制的完善任重而道远，这需从上到下以及从下至上的同心努力”。^{〔65〕}对于社会组织来讲，则要认清行业协会是一种私利政府，“仅仅依靠行业协会自身的修养和努力，来抑制它与生俱来的精英寡头统治、无政府主义和限制竞争的本能与倾向是远远靠不住的”，它离不开国家的必要监管，否则就会僵化、萎缩、固步自封而衰退为可怜保守的旧行会制度，同时，“无论如何都应以不损害行业协会的民间性为底线”。^{〔66〕}也就是说，政府不能罔顾当代市场经济和全球化趋势的发展主流和客观要求，不能一直抱着国家构建主导的传统观念不放，也不应对社会组织抱着提防和管理的心态，而应顺应历史发展潮流和社会发展需要，适时赋予社会组织以应有的民主参与和自治权利；社会组织也不能忘却自身的神圣使命和公共责任，更不可以一己之私而有损社会秩序；而对于社会公众而言，则应该逐渐熟悉和信赖民间组织，形成不依赖于政府而更多支持和参与社会组织进行自我服务和管理的习惯。这就需要全社会都能够理性地对待政府监管和社会组织自治，按照民主法治的基本精神，本着多元参与、共同建设、共同享有的基本原则，展开政府与社会组织的良性互动与合作，促进共建共享社会治理格局的形成。

其二，探索共建共享的国家与社会关系模式。从当代世界发展趋势来看，国家与社会的良性互动关系已成为主流，这就“意味着社会和国家双方通过合作而获益：社会中分散的利益按照功能分化的原则组织起来，有序地参与到政策形成的过程中去；从这种制度化的参与机制中，国家权力获得了稳定的支持来源（合法性）和控制权”。^{〔67〕}因此，“问题不在于要强化政府还是强化民间组织，而是有必要同时强化两者”。^{〔68〕}对中国而言，“如何将从先前单位制的窠臼中散落的个体再一次‘嵌入’社会本身，既是个体本身的期许所在，也是政府治理所不能回避的责任。不过，如果解决路径还是止步于完全依靠政府的力量这一点，恐怕带来的只是政府与民众双方面的不满。相反，让散落的个体重新嵌入根植于社会内部的社会组织，则成为政府和民众皆可接受的较优选择”。我们必须意识到，“在社会组

〔65〕 前引〔5〕，孙伟林文，第103页。

〔66〕 前引〔28〕，龙宁丽文，第94页。

〔67〕 张静：《法团主义》，中国社会科学出版社1998年版，第47页。

〔68〕 前引〔19〕，费希尔书，第198页。



织力量被压抑后,要激发出社会的最大活力,不但需要政府的松绑,也需要政府的扶植”。^[69]中国不可能走社会组织与国家对抗型的西方式道路,而只能根据中国的国情,走国家给予鼓励和扶持、社会组织自主发展的合作型道路,促进“强国家弱社会”向“强国家强社会”不断迈进,建立社会组织在国家政治、经济和文化生活中的民主参与、多元协商和自主治理机制,实现国家与社会的良性互动、双向构建和共建共享发展。

这一理想图景如何变成现实,是一个很复杂的实践问题。首先,要纠正激活措施受制于政策偏好。近年来,国家一直很重视社会建设、社会治理创新和社会组织体制改革,并实施了四类社会组织可依法直接向民政部门申请登记等激活措施。但是,一些具体制度规定和监管机制仍秉持着谨慎的、偏重管理的态度与偏好,只是控制方式和策略有所不同而已,社会组织的独立性、自主性和获得资源的能力仍十分薄弱,难以在多层次多领域治理中发挥更重要的作用。近年来国家主导下的“枢纽型”、“以社会管社会”为目标的社会组织建设方式,仍带有国家本位和行政延伸的色彩,并与一些发展中国家对社会组织的“收编”相似,^[70]也难以实现双向构建、互动平衡和共建共享。其次,要防止社会组织“党建”变身为“婆婆”。社会组织的党建工作当然是非常必要的,但个别地方有将党建工作演化为扮演过度的拍板“婆婆”角色的情形,制约了社会组织的自主性、积极性和民间治理功能的有效发挥。从长远来看,这些都并不利于落实“四个全面”战略布局和推进法治中国建设,需要深度的改革予以积极推进。再次,要消弭社会组织面临的“被俘获”的风险。社会组织自身也存在着动员能力不强、公信力不高、治理能力不足等问题,甚至还有被利益集团“俘获”、违法趋利的情况发生,其“双重使命”失衡的问题较为突出。可见,构建国家与社会的良性互动关系模式,打造双向构建、互动平衡、共建共享的治理格局,对于政府和社会组织来说,都尚需一个学习、适应和磨合的探索过程。

其三,构建社会组织发挥功能和作用的平台与机制。社会组织在推进共建共享法治秩序进程中所具有的重要使命和功能,无疑需要凭借一定的平台和机制才能得以实现。为落实十八届三中、四中全会决定的战略部署,2015年7—8月,国家先后公布了《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》和《深化标准化工作改革方案》,明确学会、协会、商会、联合会和产业技术联盟等社会团体可以自主发布相应的团体标准。最近,中办、国办又联合发布了“社会组织促进意见”。然而,这些举措大多还都限于政策倡导层面,并未进入实践操作层面。只有以社会组织为载体,建立起发挥实际作用的政府智库、确立人大代表的社会组织界别、建立公共政策的民主协商机制、形成政府决策的咨询论证机制、建立具有实际效果的利益群体诉愿表达和维权机制等等,并有效纳入党依法执政和政府依法行政的体系之中,社会组织才能在这些平台和机制中发挥其应有的功能和作用。

其四,培育社会组织的治理能力和社会公信力。官办社会组织官气十足,民办社会组织资源有限,而草根组织则艰难存活。他们的治理能力和水平、社会公信力都不很理想。为了解决这一问题,最近党和国家启动了以团中央为典型的群团工作改革。对此,官媒评论指出,目前群团组织的突出问题就是“衙门作风”、“职能雷同”、“代表面窄”和“内容

[69] 《激发社会活力放权与扶植需双管齐下》,《郑州日报》2012年3月28日10版。

[70] 参见前引[19],费希尔书,第123页,第37页。



空泛”，存在着“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”倾向。^{〔71〕}归结起来，就是脱离群众和边缘化，一方面端着官架子不能真正代表人民群众，另一方面，也无法有效地参与政治生活和公共事务管理。因此，要落实“社会组织促进意见”要求，无疑还有太多的工作要做，特别是培育社会组织的治理能力和公信力，就十分关键。只有更深度的体制机制改革，切实放权、赋权给社会组织，包括在业务办公场所、人员编制、工资待遇、经费支持、减免税、活动范围等方面的政府扶持和政策优惠，才能使社会组织有更大的动员能力和活动空间，训练和培养其更高的治理水平、社会公信力和承担“双重使命”的能力，为打造共建共享治理格局做出应有的贡献。

Abstract: The complicated relationship between social organizations and the construction of the rule of law during the past 40 years in China has been dominated by the “state construction” pattern. In this period, government regulators have attempted to create a new pattern of “regulation of society by society” in the process of reform, but the outcomes are not very satisfactory. Meanwhile, social organizations have been engaged in “civil construction” in their tortuous course of development, but the impact of their efforts has been weak. This has led to the functional “absence” of social organizations in the advancement of the rule of law, along with such problems as the vicious structure of social polarization, systematic risks of extractive character, weakness of self-governance order, and mal-position of state construction and civil construction, which have severely impeded the legalization of social governance. Currently, under the strategic arrangement of “Four Comprehensives”, the transition of the pattern of rule-of-law construction from that of state construction to that of “co-construction and sharing” has clearly become a historical trend. Therefore, it is necessary to reconsider the responsibilities and functions of social organizations, so that a “law-based China” can be ultimately constructed via the “co-construction and sharing” approach.

Key Words: social organizations, state construction, co-construction and sharing, order of rule of law

〔71〕 中国青年网：《共青团中央书记处关于巡视整改情况的通报》，http://qnzz.youth.cn/gzdt/201604/t20160425_7907995_1.htm，2017年5月10日访问。

